

1500142-04.2022.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2004291/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 22290306 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 17/22/112 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2004291 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DO SANTOS

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500142-04.2022.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500142-04.2022.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2004291/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 22290306 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 17/22/112 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2004291 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada [Nome da Parte Passiva Principal], devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 61/64).

Determinou-se o processamento (fls. 65)

A parte processada, devidamente notificada (fls. 86), apresentou resposta escrita (fls. 91/97). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 15 de Julho de 2022 (fl. 98) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência (fls. [TA]), foram inquiridas seis testemunhas arroladas pela acusação; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 116/119).

2. Fundamentação

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 03/05), do auto de exibição e apreensão (fls. 06/07 [AEA] e 09/11 [imagem]) e laudo toxicológico definitivo (fls. 28/30 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

A testemunha EBERTON RODRIGO POVLIIUK PARR declarou em sede policial que "(...) é agente penitenciário na unidade de Osvaldo Cruz-SP há 12 anos. No dia 03/01/2022, por volta das 16hs, juntamente com o agente penitenciário MARCEL ALESSANDRO VALESSI, realizavam o acompanhamento desembarques dos sentenciados que retornavam da Saída Temporária do final de ano (Natal/2021 e Ano Novo), e que se encontravam no ônibus da empresa Expresso de Prata. Tal desembarque ocorria já no interior da UNIDADE PRISIONAL, especificamente na sub-portaria, que dá entrada para as áreas internas dos pavilhões. Dentre os presos estava MARCOS VINICIUS DOS SANTOS. Durante o desembarque os agentes perceberam que algum dos presos havia jogado um objeto no interior do ônibus antes de desembarcar, entretanto não identificaram naquele ato qual deles havia jogado. Diante do ocorrido realizaram uma revista ao interior do ônibus, e foi encontrada uma quantidade considerável de substância esverdeada apresentando ser maconha, a qual estava embaixo de uma poltrona. Durante a revista os presos ficaram perfilados esperando. Ao indagar os sentenciados citados, Marcos Vinicius dos Santos, Matrícula 1.180.674, se apresentou por livre e espontânea vontade, dizendo ser o proprietário da substância, a qual seria para seu uso pessoal. Em seguida os agentes levaram MARCOS para a portaria onde existe um scanner corporal. Através do uso do aparelho de scanner corporal (Body Scanner), foi possível constatar algumas circunferências no estômago de Marcos. Ao ser questionado Marcos assumiu que ao perceber que seriam revistados no desembarque, engoliu 3 porções pequenas de maconha. Que o próprio preso disse que poderia expelir as substâncias ali mesmo na portaria, utilizando-se de alguns copos de água. Que então os agentes lhe entregaram alguns copos de água e MARCOS provocou "ansia" e expeliu 3 porções de maconha. O depoente assevera neste ato que as drogas expelidas por Marcos estavam embrulhadas com embalagem de borracha tipo "bexiga" a qual é comumente utilizada por presos para adentrar a unidade prisional com as drogas dentro do corpo. Informa por fim que o agenteIVALDO prestava serviços na portaria e viu o momento em que Marcos expeliu as drogas". Ratificou suas declarações em juízo.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha MARCEL ALESSANDRO VALESSI.

A testemunha Ivaldo Luiz Possari Rodrigues declarou em sede policial que "(...) é agente penitenciário há 20 anos na PENITENCIÁRIA DE OSVALDO CRUZ. Nodia 03/01/2022 exercia suas funções no setor de portaria da unidade prisional. Na tarde daquele dia os agentes EBERTON e MARCEL faziam uma averiguação junto ao preso Marcos Vinicius dos Santos, pois suspeitavam que ele trazia drogas escondidas em seu estômago. Os agentes mencionaram que já tinham passado tal preso no scanner. Em dado momento o depoente percebeu que Marcos estava expelindo alguns objetos pela boca após provocar vômito. Que o depoente notou que eram três porções de substância embrulhada em borracha, a qual é tipicamente usada pelos presos para inserirem drogas na cadeia através da ingestão de tais objetos. Sobre os demais fatos narrados neste inquérito o depoente nada sabe, pois eram os agentes Eberton e Marcel quem estavam averiguando tal situação e fizeram os demais procedimentos de praxe (...). Ratificou suas declarações em juízo.

A testemunha Alessandro Roberto Mello declarou em juízo que, na época dos fatos, trabalhava na sindicância da penitenciária de Osvaldo Cruz. No processo administrativo, o acusado confirmou que a droga apreendida no ônibus e as porções expelidas eram dele.

A testemunha ALEXANDRE LOPES STECHER declarou em juízo que participou da revista da cela do acusado no dia do seguinte aos fatos, oportunidade em que foram encontradas três porções de maconha no esgoto.

O acusado MARCOS VINICIUS DO SANTOS, ao ser interrogado em juízo, admitiu a propriedade das drogas, alegando, contudo, que se destinavam ao seu consumo pessoal.

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória (contraposta) de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida, merecem irretratável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas.

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso. Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011 caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

Portanto, de rigor a condenação do acusado. Eis o meu convencimento

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407]), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos

autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), particularmente. Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime não são desfavoráveis à parte acusada, de forma que fixo a pena em seu patamar mínimo legal - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) ano, na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ), circunstância que compenso com sua reincidência (Processo nº 1501878-78.2019.8.26.0628 – fl. 72), mantendo a pena intermediária em sua base.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) no crime de tráfico ilícito de drogas (entorpecentes), nos termos da Súmula 630 do STJ, exige o reconhecimento da traficância (ato de circular) pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que a infração foi cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais (cadeias, penitenciárias e Fundação CASA), de ensino (escolas, faculdades, universidades, cursos técnicos) ou hospitalares (lugares onde se tratam doentes, como postos de saúde, hospitais, manicômios) (art. 40, III, 1ª figura, da LD), de modo que, nos termos do art. 40 da LD, fixo a pena provisória, aumentando-a de 1/6, fixando a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente específico e as circunstâncias não são favoráveis. Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP).

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos), II (reincidência) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

O acusado se encontra preso por determinação oriunda de outro processo, razão pela qual julgo prejudicada eventual deliberação sobre custódia cautelar.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Marcos Vinicius dos Santos, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da LD, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 02 de Setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA